我国按日连续处罚与加处罚款的关系考察及其重构
——基于行政过程论的视角

张　抗*

摘要：当下行政执法实践普遍将按日连续处罚与加处罚款两个独立的单一行政行为整合成前者为主、后者为辅的复合行政行为，忽略了二者之间的逻辑关系，会导致后者在合法性审查中沦为前者的附属品。为了准确掌握二者的应然关系，有必要导入行政过程论范式，分阶段揭示按日连续处罚行政过程。微观上按日连续处罚属于行政处罚，加处罚款属于执行罚；宏观上按日连续处罚处于“作出阶段”，加处罚款处于“执行阶段”。是故，在重构二者关系时，不仅要注重各自所属的单一行政行为法规制，还要以全面动态的考察方法，正确处理二者之间的依据关系、选择关系，以及对整体行政过程的合法性、合理性要求，最终促使二者得以有效实施。

关键词：按日连续处罚；加处罚款；行政过程论；应然建构

一、问题的提出

作为公法上的金钱给付义务，加处罚款本就在法律文本和执法实践中与作为行政处罚的“罚款”难以区分，更遑论同样与加处罚款采用“按日”计算的连续罚款。按日连续处罚不是传统意义上的行政罚款，而是在责令改正后拒不改正才启动的连续罚款，与加处罚款的规范模式非常相似，很容易让人误会按日连续处罚是加处罚款的另一种行政表达。二者之间边界关系的模糊，会导致行政执法和司法适用的混乱与困惑，如以下案例所示：

案例1：在“新昌县环境保护局与新昌县和兴纺织印染有限公司非诉执行审查案”〔1〕中，面临按日连续处罚与加处罚款的一并执行申请，新昌县人民法院单独审查了按日连续处罚的合法性，但对申请执行人要求执行加处罚款的申请，以“其并未作出加处罚款的决定，没有执行

＊作者简介：张抗，山东大学法学院博士研究生。

基金项目：本文系山东省社科规划重点项目“行政审判参照惯例问题研究”（17BFJ03）的阶段性研究成果。

〔1〕新昌县环境保护局与新昌县和兴纺织印染有限公司非诉执行审查案，浙江省新昌县人民法院（2017）浙0624行审169号行政裁定书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

依据”，裁定“不予执行加处罚款”。

本案中的按日连续处罚决定，实际上包含着按日连续处罚和加处罚款的双重内容，但从裁定结果来看，法院否定了按日连续处罚决定书里“加处罚款”的有效性，并主张加处罚款应当具备单独的行政决定形式，不应和按日连续处罚混为一体。这与二者常合并于同一法律文书的现实情况有所冲突，那么，这种合二为一的行政决定形式究竟是否合法可行？如何看待按日连续处罚决定书里“加处罚款”的性质？这里的加处罚款是一种行政强制执行方式，还是一种行政告知行为？

案例2：在“惠州市生态环境局与惠州市和利牌印染有限公司非诉行政行为执行审查案”〔2〕中，与案例1不同，惠州市惠城区人民法院承认了“按日连续处罚与加处罚款合二为一”的行政决定形式，确认了按日连续处罚决定的合法性，裁定准予执行“根据按日连续规则计算的322万元罚款以及加处罚款322万元”。

本案未单独评判加处罚款的合法性，直接以按日连续处罚的合法性推定加处罚款的合法性。若按日连续处罚与加处罚款分属不同的合法性评价规则体系，这里按日连续处罚的合法性效力能否当然溯及加处罚款？若按日连续处罚合法，是否当然默认加处罚款亦合法，无需再作评判？加处罚款是否需要单独申请人民法院强制执行？另外，双倍执行连续罚款是否有违一事不再罚原则？若罚款数额超过被处罚人经济承受能力，后续出现执行不力的尴尬状况又当如何？

是故，必须反思的是，应然层面下按日连续处罚与加处罚款的关系究竟如何？如不厘清，不仅容易忽略加处罚款作为行政强制执行的独立价值，同时也会陷入加处罚款可有可无的窘境，而且过分强调二者的承接性，会使加处罚款成为按日连续处罚逾期得不到履行的当然之选，从而丧失法定执行选择的多样性和灵活性。

二、我国按日连续处罚与加处罚款的现实关系

（一）理论界对于二者关系的解读

鉴于按日连续处罚的法律属性尚有存疑〔3〕，当下行政法学理论界对于按日连续处罚与加处罚款的关系有三种解读：第一，将按日连续处罚等同于加处罚款；第二，将按日连续处罚视为类似于加处罚款的一种行政强制执行方式；第三，按日连续处罚是一种独立的行政处罚，不同于作为执行罚的加处罚款。之所以产生不同解读，主要源于按日连续处罚在制度目的和实施方式上具备执行罚的外观。

其一，从制度目的来看，按日连续处罚亦有敦促违法者及时停止违法行为的行政目的，这是有充分根据的，具体如下：首先，实施按日连续处罚的原本目的是及时纠正环境违法行为，避免违法行为对环境造成更大影响。环境保护部环境监察有关负责人曾在《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（以下简称《按日连续处罚办法》）解读中提到：“按日连续处罚制

〔2〕惠州市生态环境局与惠州市和利牌印染有限公司非诉行政行为执行审查案，广东省惠州市惠城区人民法院（2020）粤1302行审126号行政裁定书。

〔3〕理论界对于按日连续处罚的法律属性存在不少争议，有学者认为，按日计罚是一种行政制裁手段，其以动态化的方式实现违法成本与违法收益之间的均衡，以惩戒和预防环境违法行为，因而其性质应归结为一种行政罚。也有学者认为，按日计罚是一种督促义务人履行环境义务的行政措施，其重点不在于制裁既往的环境违法行为，而在于促使违法者履行停止环境违法行为的义务，因此，可以将按日计罚定性为一种执行罚。参见陈德敏、鄢德奎：《按日计罚的法律性质与规范建构》，载《中州学刊》2015年第6期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度，即按照违法排污行为拒不改正的天数累计每天的处罚额度，违法时间越长，罚款数额越高，从而实现过罚相当，有效解决‘守法成本高、违法成本低’的问题，达到督促违法行为及时改正的目的。”〔4〕部分学者以此为据，将按日连续处罚的法律属性定性为“执行罚”抑或“具有行政强制执行性质的行政处罚”。司法审判实践中对此也予以认可，譬如“北京华清佰利环保工程有限公司、固阳县金山镇生活污水处理站诉固阳县环境保护局行政处罚案”的行政判决书中在裁判理由里阐述了按日连续处罚的纠法目的。〔5〕其次，相关立法承认了按日连续处罚之督促目的。《按日连续处罚办法》和地方部分立法，譬如《天津市交通运输委员会环境保护监督管理按日连续处罚实施办法》《上海市城镇排水主管部门实施按日连续处罚办法》，均规定了“实施按日连续处罚，应当坚持教育与处罚相结合的原则，引导和督促当事人及时改正环境违法行为”。最后，按日连续处罚之督促目的得到了我国台湾理论界和实务界的支持。我国台湾学者蔡震荣认为，按日连续处罚制度“可切割为几个阶段，企图借由此不断增加之处罚，达到逼使行为人改善之目的。故除有过去义务违反之处罚性质外，更兼具有促使行为人未来履行其义务”。〔6〕同时台湾地区最高行政法院也提出了相同的主张：“按日连续处罚之目的，乃在借由不断的处罚，促使行为人履行其公法上义务，其规范目的并非在过去义务违反之制裁，而是针对将来义务履行所采取之督促方法。”〔7〕

其二，从实施方式上讲，我国《环境保护法》规定的按日连续处罚与作为“执行罚说”的“按日计罚”非常类似。“对于持续性环境违法行为，先作为‘一次’进行处罚，并通知限期改正，届期仍未改正的，则视为违法者在限期改正期间持续违法，按日连续处罚，直至改正完成”〔8〕，即“首次受到罚款＋责令改正＋拒不改正＋按日连续处罚”。首先，行政机关作出按日连续处罚之前给予违法当事人改正机会，这种机会是有限制的：一是改正内容确定，要求违法者立即停止违法排放污染物行为；二是改正时间有限，最长时间为30日，即从环保行政机关向违法者送达责令改正违法行为决定书之日起至实施复查之日的中间时间段。在责令改正期间允许违法状态之存在，一旦期限届满，若违法状态仍未得到改正，则启动按日连续处罚，且按日连续处罚可以持续性适用，次数不受限制。其次，责令改正作为按日连续处罚的前置性程序，是实施过程中承上启下的重要环节，除了发挥行政程序的工具性功能，自身内含的“执行罚”的补救性功能亦不容忽视。按日连续处罚采取按照违法行为持续的日数，不断累加罚款数额的动态罚款模式。“罚无上限”，一旦实施，相对人将遭受重大财产损失。很多企业畏于按日连续处罚的“天价罚款”，在被责令改正后，积极治理，及时改正违法行为，可见责令改正的补救功效。然而仅仅以具备相似的制度目的和实施方式将按日连续处罚等同于“执行罚”，依据不足，实为不妥。尽管现行立法对按日连续处罚的法律属性未曾明示，但要求其按照行政处罚法的规定实施，彰显了按日连续处罚属于行政处罚的理论取向。尤其是2021年修订的《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称新《行政处罚法》），更加夯实了按日连续处罚定性为行

〔4〕刘晓星：《严禁违法行为 推进依法行政——〈环境保护主管部门实施按日连续处罚办法〉解读》，载《中国环境报》2015年1月12日，第1版。

〔5〕北京华清佰利环保工程有限公司、固阳县金山镇污水处理站诉固阳县环境保护局行政处罚决定案，内蒙古自治区包头市中级人民法院（2019）内02行终53号行政判决书。

〔6〕蔡震荣：《论按日连续处罚与怠金》，载《法学讲座》第28期（2004年）。

〔7〕台湾最高行政法院101年度判字第236号判决，转引自吴志光：《行政罚连续处罚之立法政策之检讨》，载台湾行政法学会主编：《行政执行/行政罚/行政程序/政府资料开放/风险社会与行政诉讼》，元照出版有限公司2017年版，第151页。

〔8〕严厚福：《〈环境保护法〉“按日计罚”条款评析》，载《清华法治论衡》2014年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

政处罚的法律基础。

（二）行政执法视野下的关系考察

抛去理论界的争议，我国行政机关在具体执法中千篇一律地将加处罚款和按日连续处罚合并设定于同一行政处罚文书，且文书内容以按日连续处罚为主、加处罚款为辅。虽然这种“合二为一”的行政处罚文书详细载明了按日连续处罚的起止时间和依据、按照按日连续处罚规则决定的罚款数额、履行方式和期限以及相应的法律救济途径，但加处罚款往往附加在按日连续处罚决定的末尾之处，只寥寥一句带过。如矿环连罚字［2018］5号按日连续处罚决定书中的“逾期不缴纳罚款的，申请执行人可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第51条第1项之规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。”〔9〕

此种设定方式不仅事先预定了加处罚款作为按日连续处罚逾期得不到履行的常态化执行选择，而且将本应是两个独立的不同类型的单一式行政行为简化为以按日连续处罚为主、加处罚款为辅的复合式行政行为。虽然取“行政效率”之便，节省了执法成本，但无疑会引起下述质疑：其一，从形式效果上讲，此种复合式行政行为会让人产生按日连续处罚与加处罚款属于并发性关系的错觉。行政机关一旦作出该复合式行政行为并通知相对人，就意味着相对人同时收到了按日连续处罚和加处罚款的通知。将通知作为行政行为生效的起点是各国或地区行政法关于行政行为生效的一般规定，如《联邦德国行政程序法》（1997）第43条第1款规定：“行政行为以相对人或涉及的人通知的时刻开始生效。行政行为内容的有效以通知为准。”〔10〕这意味着复合式行政决定书中的按日连续处罚与加处罚款同时生效。然而，按日连续处罚与加处罚款发生在不同的行政阶段，不应出现并用的现象，合二为一的行政形式颠覆了二者法定的先后次序。其二，按日连续处罚与加处罚款均是要式行政行为，将加处罚款设定于按日连续处罚决定书之中本身触犯了条文法，缺乏形式合法性，会导致行政处罚法与行政强制法的适用尴尬。其三，这种设定的同一性容易发生程序错位与遗漏。从法律设计上讲，二者均有独立的法定实施程序，一旦“合二为一”，无疑会缩减加处罚款的两次催告程序，损害当事人的知情权、申辩权等程序性权利。此举不仅切断了程序的渐进性和衔接性，缺失程序正义，而且忽视了按日连续处罚与加处罚款之间的逻辑关联性，破坏行政行为链的完整性。其四，这种以按日连续处罚为主、加处罚款为辅的设定方式，舍弃了“加处罚款”作为执行罚的原意。将加处罚款视为按日连续处罚的部分内容，加处罚款的生效、实施、执行及合法性判断均依附于按日连续处罚，削弱了加处罚款作为一种行政行为类型的完整性和独立性。

综上所述，在按日连续处罚与加处罚款的关系配置这一问题上，无论是理论上关于二者性质的混淆，还是实践中行为形式的并用，均是以行政行为类型化模式为基础，孤立地看待二者之间的承接关系。为避免简单地将二者的行为模式叠加适用且只局限于单个行为法的规制，亟需导入新的理论范式，重新建构二者的关系。

三、理论基础建构：导入行政过程论范式

行政行为类型化技术作为“一种法教义学意义上的法律方法”〔11〕，过于注重建构单个行为

〔9〕 石家庄市井陉矿区环境保护局与河北常恒能源技术开发有限公司非诉执行审查案，石家庄市井陉矿区人民法院（2019）冀0107行审1号行政裁定书。

〔10〕 应松年主编：《外国行政程序法汇编》，中国法制出版社2004年版，第98页。

〔11〕 周海源：《行政权力清单制度深化改革的方法论指引》，载《政治与法律》2019年第6期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法的合法性评价规则体系，“缺乏对行政过程中各种行为形式之间的关联性分析”〔12〕。这种孤立的、静态的考察方法无法适应日趋复杂、变化多端的现代行政行为，也不能涵盖所有的现实行政活动。“现代行政法学不再局限于单一的、静止的行政行为，从而将行政行为以外的其他各种行为形式纳入行政法学的视野进行探讨，并对各种行为形式之间的相互关系加以全面、动态的考察。”〔13〕不少学者开始推崇“行政过程论”，任何一个完整的行政活动都是颇为复杂的连续过程，由若干环节（步骤）组成并分阶段进行。〔14〕基于此，不同学者对行政过程的阶段性法律构造提出了各自见解〔15〕，虽然内容不一致，但均强调全面、动态考察方法的应用，“据此发现和挖掘行政法教义学所忽略的过程要素，进而寻求建构一套更契合于现代公共行政之复杂性的行政法学理论范式”〔16〕。

按日连续处罚作为不同于一般处罚的一种新型行政活动形式，其实施过程是由一系列相互关联的复数行政行为构成的结合体，并非通过单个行政处罚行为就能实现，还有可能涉及行政命令、行政强制、行政诉讼等其他类型的行政行为。因此，不应局限于对按日连续处罚的单个行为进行合法性评价，而应考虑与其他行政行为之间的关联，将其纳入整个行政过程进行考察。否则，不仅会产生不同法律之间的适用冲突，而且会影响按日连续处罚的合法性判断以及实现的程度。显然，传统行政行为理论无法对按日连续处罚的过程性作出合理解释，“在适用传统行政行为理论难以为按日连续处罚提供充分范式解释的情况下，实有必要通过对按日连续处罚这一行政过程的动态、全面考察，为其适用的法治化提供必要的范式支撑”。〔17〕由此可以将按日连续处罚这一行政过程分为四个阶段：准备阶段、作出阶段、执行阶段和救济阶段。准备阶段是指按日连续处罚启动之前必须具备某些行为形式的事前阶段，包括相对人被发现违法排污后受到的首次罚款、被责令改正以及拒不改正；作出阶段是指违法者被责令改正且拒不改正后，行政机关正式启动按日连续处罚的事中阶段；执行阶段既包括违法者及时履行按日连续处罚的自我执行，也包括违法者逾期不履行按日连续罚款义务时行政机关实施的强制执行；救济阶段是指相对人不服按日连续处罚决定时，向有关国家机关提出申请，对自身合法权益进行救济的事后阶段，主要包括行政复议和行政诉讼。“这些前后连续的、相对独立而又相互关联的行政行为形成一条行政行为链”〔18〕，全面展现了按日连续处罚行政过程的动态发展。但是，并非所有的按日连续处罚过程都要历经上述四个阶段，如果相对人被责令改正后及时停止违法

〔12〕高秦伟：《行政过程中的政策形成——一种方法论上的追问》，载《当代法学》2012年第5期。

〔13〕江利红：《论日本行政法学中的行政过程方法论》，载《法律方法》2015年第2期。

〔14〕参见朱维究、阎尔宝：《程序行政行为初论》，载《政法论坛》1997年第3期。

〔15〕有学者从行政过程论的视角出发，将现实行政过程划分为宏观行政过程与微观行政过程，前者是由复数行政行为构成的过程，分为“标准阶段”“行为阶段”“执行阶段”和“救济阶段”；后者划分为“法律事实认定阶段”“法律规范适用阶段”“决定作出阶段”和“决定送达阶段”。参见江利红：《行政过程的阶段性法律构造分析——从行政过程论的视角出发》，载《政治与法律》2013年第1期。还有学者提出单一式行政行为的过程性和复合式行政行为的过程性，前者包括调查取证的准备阶段、作出决定阶段和行政行为的实现阶段，后者包括了行政立法阶段、作出行政行为阶段、执行阶段、监督救济阶段。参见朱维究：《再谈现代行政过程论——从形式行政法治到实质行政法治》，载中国法学会行政法学研究会：《行政管理体制改革的法律问题——中国法学会行政法学研究会2006年年会论文集》，第72—73页。

〔16〕周海源：《行政权力清单制度深化改革的方法论指引》，载《政治与法律》2019年第6期。

〔17〕刘佳奇：《对按日连续处罚适用问题的法治思考——兼评〈环境保护主管部门实施按日连续处罚办法〉》，载《政治与法律》2015年第7期。

〔18〕朱维究：《再谈现代行政过程论——从形式行政法治到实质行政法治》，载中国法学会行政法学研究会：《行政管理体制改革的法律问题——中国法学会行政法学研究会2006年年会论文集》，第73页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

排污行为，行政机关就不会作出按日连续处罚；如果相对人及时缴纳了连续罚款，就没有后续的强制执行和救济阶段。

然而，执法实践中行政机关往往在按日连续处罚决定书中附带加处罚款的决定，即一旦相对人逾期不缴纳按日连续罚款，行政机关就会选择加处罚款的强制执行方式，迫使当事人履行自身义务。虽然此举有助于节省执法成本，但按日连续处罚和加处罚款分属两种不同的行政行为，二者并用的做法明显违背了它们各自所属的单一行政行为法规制。为了正确适用按日连续处罚与加处罚款，促使二者得以有效执行，除了要在微观行政过程中确保二者符合各自的合法性评价规则体系，还应在宏观行政过程中全面动态地把握二者的关联性和承接性。

四、微观行政过程中的应然建构：与行为类型相匹配的适法

微观行政过程是单一行政行为的过程。当下我国行政行为法体系是借助行政行为类型化技术得以建构的。“行政机关在执法活动中开展的各种强度与形式各异的权力活动都可从行政行为法中找到对应的行为类型，从而将权力纳入行政行为法之规制范围内。”〔19〕按日连续处罚与加处罚款作为两种不同的行政行为，应受各自行政行为法的约束与调整。

（一）明确按日连续处罚的行为属性

要想构建按日连续处罚与加处罚款之间的关系，前提是必须明确按日连续处罚的法律属性。鉴于我国行政处罚法是一部规范行政处罚行为且涵盖程序性与实体性规则的基本法律，本身为行政处罚的界定设定了形式标准和实质标准，我们亦应从形式标准和实质标准两个层面双向把握按日连续处罚的法律属性。笔者将结合新《行政处罚法》的立法特点和修改内容重新定义行政处罚的界分标准与实质内涵，以此判断按日连续处罚是否属于行政处罚。

首先，从形式标准上判断某个行政行为是否属于行政处罚，要比对是否属于新《行政处罚法》第9条规定的五种处罚种类，或是依据第9条第6项设定的兜底条款，看法律、行政法规是否明示抑或在“罚则”和“法律责任”章节规定了其他行政处罚种类。虽然有学者对这一标准提出了质疑，认为此举是对立法者判断的过度依赖，不利于对行政处罚进行准确界定，难以成为判定行政措施性质的有效方式〔20〕，并提出了“实质标准说”。固然，实质标准能够从法理上更好体现行政行为的内在特性，可作为界定行政处罚的主要标准，但其不是唯一标准，因为它“本质上是一种价值衡量，其过于偏重个案正义，具有高度的不确定性，无法成为稳妥的立法选择”〔21〕。而形式标准能够通过立法文本直观表达行政处罚的适法性要求，是区分行政处罚与其他行政行为的直接依据。新《行政处罚法》列举的行政处罚种类中虽没有按日连续处罚，但依旧保留了法律和行政法规对行政处罚的设定权，这与《环境保护法》将按日连续处罚的设定授权给地方性法规的规定具有一致性，而且《环境保护法》修订前后的立法状况几乎将按日连续处罚列入了“法律责任”章节。如此看来，按日连续处罚完全符合行政处罚的形式标准。若将按日连续处罚定性为执行罚，不仅与《行政强制法》将行政强制执行的设定权限于法律之规定产生位阶冲突，而且无须在环保法律法规中另行规定，此观点亦得到了理论界的支持。有论者认为：“执行罚得连续处罚，本无待法律规定，秩序罚（行政处罚）欲连续裁罚，必须法

〔19〕 周海源：《行政权力清单制度深化改革的方法论指引》，载《政治与法律》2019年第6期。

〔20〕 转引自马怀德：《〈行政处罚法〉修改中的几个问题》，载《华东政法大学学报》2020年第4期。

〔21〕 马怀德：《〈行政处罚法〉修改中的几个问题》，载《华东政法大学学报》2020年第4期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有明文规定，只要法律条文有连续处罚规定，应视为秩序罚（行政处罚）而非执行罚。”〔22〕

其次，判断某个行政行为是否属于行政处罚，除了依靠形式标准，还要注重该行为的实质内涵是否符合行政处罚的本质属性。按照传统的行政理论观点，行政处罚的本质属性是“制裁性”。所谓制裁，是指针对违反社会规范的行为，以否定或者使行为人放弃此种行为目的而启动的反作用力，其内容是剥夺一定的价值、利益或者课以一定的负价值和不利。〔23〕这一定义将所有对行为人的不利处分纳入了制裁的范畴，无法准确表达出行政处罚真正的内涵。实际上，行政处罚不仅仅是一种制裁措施，还有纠正违法行为的重要目的，具备教育和预防的功能。新《行政处罚法》第9条增加的“通报批评”、第33条规定的“首违不罚”“无主观过错不罚”和“不处罚时也要教育”等新内容强化了行政处罚的教育功能，表明行政处罚并非为罚而罚，而是要达到预防违法的实际效果。最为关键的是，新《行政处罚法》第2条增加了“行政处罚”的概念条款，即“行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。”该定义是判断一个行政行为是否属于行政处罚的重要实质性标准，因为它“抓住了行政处罚区别于其他行政行为的两个核心特征，一是处罚实现的具体形式（减损权益或者增加义务），二是处罚的性质（惩戒）”〔24〕。显而易见，按日连续处罚通过连续罚款减损相对人的财产权益，符合第一个特征。“惩戒”一词揭示了行政处罚的本质属性，意为“惩戒过错，警戒将来。也指引以为戒，即以过去的失败作为教训”〔25〕。由此推出，行政处罚应具备“惩罚”与“预防”两个功能，且“惩”在前，“戒”在后，暗含着以惩罚性为辅，预防性为主的功能内核。有论者指出“惩戒”包含通过惩罚来劝诫与预防违法行为的意思，而对违法行为的劝诫与预防乃惩罚的应有之意，或者说惩罚所应有的附随效果，再以“惩戒性”来描述行政处罚的特征有画蛇添足的倾向。〔26〕笔者以为，将惩戒作为行政处罚的实质内涵，乃是为了强调劝诫与预防的法律效果。相较于制裁而言，“惩戒对行政处罚的定位更为精准，更符合行政处罚的原则和特征，既有惩，又有戒，能够体现行政处罚‘处罚与教育相结合’的原则和精神，兼顾行政处罚的教育、威慑与预防功能”〔27〕。按日连续处罚的目的不仅仅限于督促原有义务之履行，还强调对违反行政秩序行为给予连续罚款的重罚，借由重罚将特别预防功能予以极大化，警戒违法排污者再犯，与行政处罚的惩戒之内涵相当契合。

最后，从行政处罚的构成要件来说，主要争议点在于受处罚行为是否应具备可归责性。当下理论界有过错原则、过错推定原则和客观归责三种观点，但2021年修订之前的《行政处罚法》没有主观归责的规定。实际上行政处罚应有可归责性在国外和我国台湾地区早有立法经验，如德国《违反秩序法》第10条、奥地利《行政罚法》第5条以及我国台湾地区“行政罚法”第7条，此种观点同时也得到了洪家殷、蔡震荣等我国台湾学者的赞同。令人振奋的是，新《行政处罚法》第33条规定：“当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。”该条款首次明确了“无主观过错不予处罚”的内容，此举不仅是我国行政处罚法制史上的重大进步，而且与按日连续处罚的归责标准不谋而合，正

〔22〕 吴庚：《行政法之理论与实用》（增订12版），三民书局出版社2012年版，第533—534页。

〔23〕 参见［日］左伯仁志：《制裁论》，丁胜明译，北京大学出版社2018年版，第5—6页。

〔24〕 应松年、张晓莹：《〈行政处罚法〉二十四年：回望与前瞻》，载《国家检察官学院学报》2020年第5期。

〔25〕 辞海编辑委员会：《辞海》，上海辞书出版社1979年版，第3653页。

〔26〕 参见陈太清：《罚款的补偿性研究》，南京大学2011年博士学位论文，第80页。

〔27〕 应松年、张晓莹：《〈行政处罚法〉二十四年：回望与前瞻》，载《国家检察官学院学报》2020年第5期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

好填补了按日连续处罚中关于“拒不改正”的评判标准在法律依据上的空白。一般情况下，行政机关和司法机关基本上凭借“拒”字包含的主观意味，推测出“拒不改正”是对排污者履行改正义务的一种兼顾主观与客观的评价标准，其中“不改正”是客观上造成的结果，而“拒不”则表明其主观上的抗拒状态。新《行政处罚法》实施后，行政机关决定是否作出按日连续处罚，应该依法判断违法者在主观上是否有过错。即使排污者未能按期完成改正义务，也应考察其主观上是否存在拒不履行的过错情况。只有主客观条件同时满足，“拒不改正”方能成立并可对排污者施以按日连续处罚。如果排污者确已着手改正并为之努力而未收改正之效，不应视为“拒不改正”而武断地适用按日连续处罚。值得注意的是，执行罚不在乎当事人是否存在主观过错，只看客观表现，只要一日没履行义务，执行罚就反复适用。是故，按日连续处罚定性为行政处罚更为妥当。

（二）遵循分别执行的处理原则

司法实践中往往面临按日连续罚款和加处罚款的一并执行申请，有的法院持“肯定说”，譬如菏泽市中级人民法院作出了限期缴纳连续罚款及加处罚款的裁定；〔28〕有的法院持“反对说”，浙江省新昌县人民法院作出了准予执行连续罚款却不予执行加处罚款的裁定；〔29〕有的法院对加处罚款的执行申请不做评判，也对加处罚款的部分不予审查。〔30〕那么，按日连续处罚究竟能否与加处罚款一并执行？

其一，从域外和我国台湾地区的立法经验来看，对于执行罚的执行程序，德国的处理原则是适用基础行为的执行程序。“德国立法均明示或暗示行政强制执行是一种‘行政处分’，从而名正言顺地为它设定了与一般行政处分相同的法律救济。”〔31〕我国台湾“行政执行法”规定“怠金，逾期未缴纳者，移送行政执行处依第二章之规定执行之”，第二章规定的是“金钱给付义务之执行”。换言之，作为行政罚的罚金和执行罚的怠金在执行程序上一致，原因有二：“一是旧‘行政执行法’，把行政执行定位为一种行政处分，新‘行政执行法’回避了其性质定位，二是‘行政执行是一种行政处分’是台湾学界的主流观点”。〔32〕按照德国公法理论，我国大陆的行政处罚应属于基础性行为，执行罚应属于执行性行为，“不是一种处罚，而是一种督促方法；它不是针对非法行为的制裁，而是强制实施将来行为的手段”〔33〕。是故，我们不可盲目地照搬德国和我国台湾立法，对于不同行为类型的行政处罚和执行罚应当分别执行。

其二，在不同的行政语境中，按日连续处罚与加处罚款的行为范畴不同，应对两者加以区分。在国际行政法学上，特别是德、奥、日三国，对于行政强制早有“基础行为”与“执行行为”的划分理论。〔34〕依此推导，在“原罚款处罚与加处罚款”中，前者是基础行为，后者是执行行为；在“原罚款处罚与按日连续处罚”中，前者是基础行为，后者是执行行为；在“按日连续处罚与加处罚款”中，前者是基础行为，后者是执行行为；在“原罚款处罚、按日连续

〔28〕菏泽市环境保护局与郓城县金腾玻璃有限公司非诉执行审查案，菏泽市中级人民法院（2015）菏行审字第11号行政裁定书。

〔29〕新昌县环境保护局与新昌县和兴纺织印染有限公司非诉执行审查案，浙江省新昌县人民法院（2017）浙0624行审169号行政裁定书。

〔30〕武汉市环境保护局与武汉高新热电有限责任公司再审复查与审判监督案，湖北省武汉市江汉区人民法院（2016）鄂0103行审1号行政裁定书。

〔31〕胡建淼：《论德国的行政强制执行制度及理论》，载《公法研究》2002年第00期。

〔32〕胡建淼：《论中国台湾地区的行政执行制度及理论》，载《法学论坛》2003年第5期。

〔33〕［德］哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社2000年版，第487页。

〔34〕转引自胡建淼：《行政强制法研究》，法律出版社2002年版，第40页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

处罚与加处罚款”的共存关系中，“加处罚款”既可以是逾期不缴纳原罚款的执行行为，也能够成为逾期不缴纳连续性罚款的执行行为。正如德国学者鲍尔教授所主张的“没有基础性行政行为就不能有执行性行政行为。但同时两者又有着严格的区分，并须分开加以判断。”〔35〕

其三，从保护相对人的程序性权利而言，按日连续处罚与加处罚款应分别执行。不同于行政处罚的一般程序，加处罚款有着自己的一套实施程序，主要环节是：按日连续罚款决定已作出——催告——当事人陈述和申辩——作出加处罚款执行决定——送达加处罚款决定执行书——再次催告——强制执行。行政实践中的习惯做法是将按日连续处罚和加处罚款的决定合二为一，在行政处罚决定书的结尾处告知逾期将承担加处罚款的法律后果，在一并申请强制执行之前进行一次催告。该做法是非常不严谨的，不仅简化了加处罚款决定的内容，而且省略了中间的一些步骤，容易构成程序违法，譬如没有进行事先催告或未告知加处罚款的标准、催告内容错将加处罚款表述为滞纳金等。前者属于未告知和告知不全面，等于剥夺了当事人的知情权和申辩权；后者属于于法无据，等同于未告知，对当事人的程序性权利产生实质损害。权利无小事，为避免此类情况发生，行政机关应分别作出加处罚款和按日连续处罚的决定，按照各自的程序步骤依法实施，促使加处罚款在非诉执行中具备单独的可执行性。

（三）分别制作按日连续处罚决定书和加处罚款强制执行决定书

法律文书既表明了具体行政行为的种类，也决定了其是最终的、成熟的、并产生公定力、确定力的行政行为。“就具体行政法律文书而言，每一个文种又有每一个文种的特殊要求”，因此，制作行政法律文书时须“特别注意正确适用行政法律规范作为依据并严格遵循法定的时限要求”〔36〕。从法律设计上讲，按日连续处罚和加处罚款的决定均是载明相关事项的要式行政行为，但具体实践中问题有二：一是未依法制作处罚决定书和强制执行书；二是“书”中载明事项不合“法定”。两种情况均构成程序违法，并由于分不清行政行为的成立、生效、违法程度（轻微违法、违法、无效），发生司法误判。庆幸的是，新《行政处罚法》取消了“行政处罚不成立”的说法，第38条在界定行政行为的无效时，增添了“实施主体不具有行政资格”和“违反法定程序且构成重大违法”的违法事由，明确了构成无效行政行为的具体情形。

首先，结合新《行政处罚法》和《按日连续处罚实施办法》，按日连续处罚作为一项行政处罚，应当由行政机关依法制作处罚决定书。“书面形式是行政行为成立的必要形式或者载体，失却了书面这一载体，也就不能展现意思表示或行为内容。”〔37〕与此同时，处罚决定书也应当载明法定事项（譬如初次检查发现的环境违法行为及该行为的原处罚决定、拒不改正的违法事实和证据、按日连续处罚的起止时间和依据等）才能生效。需要指出的是，行政机关的行政执法文书是具有行政拘束力的规范性文件，应当做到格式规范，结构严谨，用语准确，有理有据，并运用事实依据和法律依据充分说理，有足够的依据和理由让行政相对人信任行政行为的正确性。但是行政机关在执法过程中可能为了提高效率抑或为罚而罚，在按日连续处罚决定书里有的只表明了罚款总额，未曾说明连续处罚的规则；有的对事实依据和法律依据说理不够充分。在此类情况下，按日连续处罚的决定虽已成立，但违反法定程序且构成重大违法，属于适用法律、法规错误，应界定为无效行政行为并予以撤销。遗憾的是，司法实践中经常将其简单

〔35〕全国人大常委会法制工作委员会、德国技术合作公司：《行政强制的理论与实践》，法律出版社2001年版，第19页。

〔36〕程进：《行政法律文书若干问题探讨》，载《法商研究》1997年第4期。

〔37〕柳砚涛：《质疑“行政处罚决定不能成立”——以我国〈行政处罚法〉第41条为分析对象》，载《政治与法律》2017年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地认定为“程序瑕疵”，如有判决认为：“虽然原市环保局作出的（2018）15号《行政处罚决定书》对证据分析认定不够全面，未运用事实依据和引用《按日连续处罚办法》的相关条文进行充分说理，未详细阐明处以罚款的计算标准、计罚日数的计算方式等，致使该行政行为存在一定的瑕疵，但该瑕疵不影响该行政处罚的成立。”〔38〕究其原因，程序“瑕疵”理念泛滥才是关键所在，将本属于“无效”的程序违法定性为程序“瑕疵”。

其次，《行政强制法》第37条要求“强制执行决定应当以书面形式作出并载明相关事项”。加处罚款作为行政强制执行的一种方式，理应由行政机关按照法律规定，依法作出《加处罚款强制执行书》。但当下行政实践中，将加处罚款的内容附于行政罚款处罚决定书之中的这种做法，一般只是告知了逾期将承担加处罚款的后果，省略了加处罚款所应载明的具体事项。针对这种情况，有论者认为它实际上属于行政告知行为，加处罚款并未成立。如有裁定认为：“行政机关在履行期届满后并没有对加处罚款单独作出行政决定，该具体行政行为未成立，申请执行加处罚款于法无据，故不予支持。”〔39〕行政行为的“不成立”本质上应该是指行政行为尚未作出，不具备对外的效果意思，也不产生任何法律上的效果。“不成立”本身不属于对行政行为效力状态的判定。〔40〕也有论者认为它构成无效行政行为，“对于某些要式行政行为，如对于《行政强制法》第37条规定的‘强制执行决定’而言，没有依法制作法律文书，就等于没有满足法律明确要求的要式条件，从法理上说完全可以构成无效行政行为的‘重大且明显违法’情形”〔41〕。无论是定性为“不成立”还是“无效”，均表明这种做法不可取。因此，为了确保加处罚款的合法性和可执行性，应当单独制作强制执行的决定书，正如有论者所言：“为保证罚款决定的实施，行政机关作出加处罚款的，应当作出《加处罚款决定》，对于加处罚款的比例作明确的规定。”〔42〕另外，上海市高级人民法院《关于非诉行政执行案件若干问题的解答（二）》第9条关于具体行政行为涉及加处滞纳金或罚款的处理中也规定了“对涉及加处罚款的，加处罚款属执行罚，行政机关未另行作出加处罚款行政决定，一并申请执行加处罚款内容的，对加处罚款部分裁定不予执行”，从侧面要求行政机关应当另行作出加处罚款的决定。

（四）区分计算原处罚行为的行政复议、诉讼期间

按日连续处罚与加处罚款均以原处罚行为为适用前提，问题在于二者计算罚款的时间是否应包括原处罚行为的行政复议、诉讼期间。《行政复议法》第21条和《行政诉讼法》第56条规定了行政复议、行政诉讼期间“不停止执行行政行为为原则、以停止执行为例外”，赋予行政相对人对某一行政行为进行行政复议、行政诉讼的救济性权利。此举是为了保障行政相对人的合法权益不受侵害，而非不是使该救济性权利成为拖延履行法定义务的理由。

首先，按日连续处罚决定应当在原处罚决定之后作出。按日连续处罚决定必须在受到首次罚款处罚、被责令改正、拒不改正之后才能作出，时间上晚于原处罚决定作出的时间。被处罚者对原处罚决定提起行政复议或诉讼的，按日连续处罚不停止实施，诉讼期间理应计算在内。换言之，按日连续处罚可以在行政复议、诉讼结束之前作出。如有裁定认为：“按日连续处罚

〔38〕四川双龙实业有限公司诉资阳市生态环境局环境行政处罚纠纷案，四川省资阳市雁江区人民法院（2019）川2002行初1号行政判决书。

〔39〕田东县市场监督管理局与潘林非诉执行审查案，广西壮族自治区田东县人民法院（2019）桂1022行审341号行政裁定书。

〔40〕参见马怀德：《〈行政处罚法〉修改中的几个问题》，载《华东政法大学学报》2020年第4期。

〔41〕柳砚涛：《认真对待行政程序“瑕疵”——基于当下行政判决的实证考察》，载《理论学刊》2015年第8期。

〔42〕胡锦光：《行政处罚研究》，法律出版社1998年版，第246页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

决定并不以原处罚决定是否合法为前提，故是否对原处罚决定提起行政诉讼，不影响按日连续处罚决定的作出。”〔43〕值得注意的是，按日连续处罚告知书不受原处罚决定作出时间的限制，亦可在原处罚决定作出之前发出。

其次，加处罚款的计算依据应当是生效的行政处罚决定。最高人民法院在《关于行政处罚的加处罚款在诉讼期间应否计算问题的答复》规定：“对不履行行政处罚决定所加处的罚款属于执行罚，在诉讼期间不应计算。”此复作出后，面临两个问题：一是复议期间是否可以计算加处罚款？司法审判中大多以此复为据，复议、诉讼期间一律不计算加处罚款。毕竟如因相对人依法行使复议、诉讼权利而导致其加处罚款的增加，不仅有悖于设定行政处罚及执行罚的目的，也违背了行政复议法和行政诉讼法所要达到的保护相对人实体上的合法权益和促进行政机关依法行政的立法宗旨。二是虽有此复，但仍有法院作出“加处罚款的计算不应扣除行政复议及行政诉讼期间”的行政判决。〔44〕新《行政处罚法》第73条规定：“当事人申请行政复议或者提起行政诉讼的，加处罚款的数额在行政复议或者行政诉讼期间不予计算。”此条款扩展了最高院的司法解释内容，加处罚款在诉讼期间和复议期间均不应计算，为行政审判实务提供充足的法律依据，避免因复议、诉讼期限过长而导致加处罚款数额过高、加重被处罚人的负担，显失公平。是故，行政相对人不服原处罚决定提起复议、诉讼的，为了符合立法主旨，又能保证行政公平，对加处罚款的计算应实行中断与完成制度。行政相对人在加处罚款计算尚未达到最高限额时提起复议或诉讼的，中断对加处罚款的计算，加处罚款自法院生效判决明确原处罚的合法性后重新计算；行政相对人收到原处罚决定书后，既不履行义务，又怠于提起复议或诉讼，导致加处罚款的计算达到最高限额的，加处罚款计算完成，行政相对人再次提起诉讼的，不影响对已经计算完成的加处罚款的执行。

五、宏观行政过程中的应然建构：全面动态考察

“在宏观层面上，行政过程论认为行政活动是多个阶段性行政方式和法律关系联结而成，且各要素之间关系紧密、时间连续以及目标一致。”〔45〕参照前文按日连续处罚行政过程的“四阶段理论”，理想状态下的行政过程应为：准备阶段（包括首次罚款、责令改正、拒不改正）—作出阶段（按日连续处罚）—执行阶段（加处罚款）—救济阶段（行政复议、诉讼）。按日连续处罚处于“作出阶段”，加处罚款处于“执行阶段”，从时间序列上讲，二者之间是先后的连续性关系，但这种连续关系不是必然的。

（一）正确处理按日连续处罚与加处罚款之间的依据关系、选择关系

1. 按日连续处罚优先适用

除了时间上的先后次序性，按日连续处罚与加处罚款之间还具有依据关系。“所谓依据关系，是指同一宏观行政过程中的前一行为是后续行为的依据或标准。”〔46〕前者为后者提供依

〔43〕永宁博盛水务有限公司诉永宁县环境保护局、永宁县人民政府行政处罚案，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2018）宁0106行初178号行政判决书。

〔44〕信和财富投资管理（北京）有限公司济南第三分公司诉济南市市中区市场监管局、市中区人民政府行政处罚案，济南市中级人民法院（2019）鲁01行终98号行政判决书。

〔45〕范伟：《食品安全监督抽检制度的规范构建——基于行政过程论视角的分析》，载《中外法学》2021年第1期。

〔46〕江利红：《行政过程的阶段性法律构造分析——从行政过程论的视角出发》，载《政治与法律》2013年第1期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据，后者是对前者的执行。

首先，“执行阶段”的加处罚款以当事人逾期不履行按日连续处罚为适用前提。按日连续处罚决定只是行政机关依法对相对人权利义务的一种强制性判定结论，不代表连续罚款能被顺利执行。倘若相对人恶意拖延、逃避或拒不缴纳罚款，行政机关亦没有采取措施强制其履行义务，那么按日连续处罚仅仅是从书面上否定了相对人排污行为的合法性，而该处罚确定的罚款缴纳义务并未得到履行，也就达不到阻却违法排污行为的立法目的。按照行政过程论的要求，除了对按日连续处罚单一式行政行为进行合法性判断，还要关注按日连续处罚的执行过程和实施效果。当相对人不履行按日连续处罚确定的罚款义务时，行政机关可以通过行政强制执行以确保处罚的威慑效果，以加处罚款的方式督促当事人及时缴纳按日连续罚款。

其次，这种“依据关系”决定了按日连续处罚的基础地位和加处罚款的执行地位。没有前者，必然没有后者的适用空间，且后者罚款数额是以前者罚款数额为计算基数。换言之，在同一行政过程中，按日连续处罚属于基础性行政行为，加处罚款属于执行性行政行为（亦称保障性行政行为）。“基础性行为与保障性行政行为相比，是整个行政权力运行链条中的前端环节，是优先行政措施或手段；保障性行政行为是以违反法律规定或基础性行为为前提，是整个行政权力运行链条中的后端环节，不具有优先性，并规定严格的法定程序与条件。”〔47〕因此，按日连续处罚相较于加处罚款具有适用的优先性。当相对人主动缴纳按日连续罚款或者按日连续处罚原决定违法时，则无需加处罚款；当按日连续处罚的原决定合法有效且遇有执行阻碍时，加处罚款才有适用的可能性。

2. 加处罚款是可选择的后续保障

除了上述讨论的按日连续处罚与加处罚款之间的依据关系外，二者之间还具有选择关系。“选择关系，是指在同一宏观行政过程中行政机关在决定作出某一行为时存在着复数的选择，此时，这些行为之间就具有了选择关系。”〔48〕当相对人不履行按日连续处罚确定的金钱给付义务时，行政机关面临多样化的执行措施。之所以将加处罚款作为常态化选择，原因有二：一是遵循“间接强制优于直接强制”原则。只有在无法采用代执行、执行罚的情况下，或者虽采用了代执行或执行罚，仍难以达到执行目的时，才能适用直接强制，即行政强制执行应当按照由轻至重的程度进行。相较于其他执行措施，加处罚款只是剥夺当事人一定的财产能力，惩罚力度最小，欲以对当事人损害最小的方式达到行政目的，符合比例原则的精神。二是加处罚款是被《行政强制法》普遍授权的一种强制执行方式〔49〕，无需通过专门法律另行授权。任何依法作出金钱给付义务行政决定的行政机关，在当事人逾期不履行该行政决定时，都有权依法“加处罚款”〔50〕，当然包括依法作出按日连续处罚的环保行政机关，而其他执行措施均有“根据法律规定”的立法限制，无法直接行使。从实际操作来看，适用加处罚款更为简便，且易于执行。

〔47〕 薛艳华：《环境行政命令与环境行政处罚的错位与匡正——界分基准与功能定位的视角》，载《大连理工大学学报（社会科学版）》2019 年第 6 期。

〔48〕 江利红：《行政过程的阶段性法律构造分析——从行政过程论的视角出发》，载《政治与法律》2013 年第 1 期。

〔49〕 参见乔晓阳主编：《〈中华人民共和国行政强制法〉解读》，中国法制出版社 2011 年版，第 50 页；信春鹰主编：《中华人民共和国行政强制法释义》，法律出版社 2001 年版，第 50 页。

〔50〕 胡建淼：《论作为行政执行罚的“加处罚款”——基于〈中华人民共和国行政强制法〉》，载《行政法学研究》2016 年第 1 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

值得注意的是，加处罚款不是必然的执行选择。新《行政处罚法》第72条规定了行政机关面对当事人逾期不履行行政处罚决定可以采取的四种措施：（1）加处罚款；（2）查封扣押或冻结；（3）法律规定的其他强制执行方式；（4）申请人民法院强制执行。该法条属于授权性条款，即行政机关可以从中任选一种措施，加处罚款只是其中的一种保障性选择。问题是，四种措施是否可以重叠适用？有论者从立法技巧的角度分析，四种选项是平行并列的关系，即行政机关只能从中选择一种适用，不得重叠适用；〔51〕有论者则坚持法无禁止即可为，认为四者并非简单的排斥关系，“都是行政处理方式，只要其中一种能够实现强制的目的，其他方式就不应该被并用。加处罚款与申请法院执行并非两种执行方式的并列关系，因此是可以并用的”〔52〕。总而言之，无论是平行并列关系还是重叠适用关系，加处罚款都不是当事人逾期不缴纳按日连续罚款时的唯一执行措施。只要没有实现排污者停止违法排污行为的最终目的，行政机关尚可选择查封扣押或冻结汇款、存款划拨抵缴罚款、直接申请法院强制执行等其他措施。有裁定认为：“加处罚款是行政强制执行的方式，属于执行罚。针对不履行处罚决定而加处的罚款，行政机关可通过其他方式解决，而并不必然的应当另行作出行政处罚决定。”〔53〕

3. 行政机关在作执行选择时应考虑当事人的金钱给付能力

无论是按日连续罚款还是加处罚款，皆为对行政相对人财产权之侵害。按日连续罚款数额一般较大，动辄上百万；加处罚款的数额是每日按照罚款数额的3%计算且不能超出罚款的数额〔54〕，一旦相对人逾期不缴纳按日连续罚款的时限超过三四十余天，加处罚款数额就能达到按日连续罚款的数额，执行结果便是双倍的按日连续罚款。

首先，双倍执行按日连续罚款并不触犯一事不再罚原则。新《行政处罚法》对该原则增加了从一重罚的内容，即“同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚”，适用前提是“同一个违法行为”。虽然按日连续处罚与加处罚款的执行标的均是金钱给付义务，但前者是对于当事人被发现违法排污行为后拒不改正的继续性行为，处在行政过程的“作出阶段”，意在惩戒，属于“行政处罚”；后者是对于当事人被按日连续处罚后拒不缴纳罚款的行为，处在行政过程的“执行阶段”，意在督促，是“执行罚”。二者针对的是同一违法主体但却是不同阶段和性质的违法行为，虽然两个罚款数额一样，但也不属于一事不再罚原则的禁止适用对象。〔55〕正如有学者所言：“由于行政上之强制执行性质上并非处罚，故其与行政秩序罚性质不同而各有其所欲达成之行政目的，因此两种行政手段同时采行应不违反一事不再罚原则。”〔56〕

其次，按日连续处罚的实施次数不受限制。行政机关在金钱利益的驱动下，可能作出为罚而罚、以钱代罚等违法行政行为，形成“按日连续罚款＋加处罚款”的循环怪圈。为了避免此类现象发生，加处罚款在两种情形下不再是最佳执行选择：一是当事人的逾期不履行不是出于

〔51〕参见卫龙君、雷爱红：《非诉行政执行中对〈行政处罚法〉第五十一条的理解和适用》，载中国法院网，http://www.pinlue.com/article/2019/03/3019/328504549850.html，2022年2月10日访问。

〔52〕于立深：《〈行政强制法〉实施中若干争议问题的评析》，载《浙江社会科学》2012年第7期。

〔53〕洋浦经济开发区食品药品监督管理局与王文月行政处罚非诉执行审查案，海南省洋浦经济开发区人民法院（2019）琼9701行审1号行政裁定书。

〔54〕为了与《行政强制法》在加处罚款内容上保持一致，新《行政处罚法》第72条第1项添加了“加处罚款的数额不得超出罚款的数额”。

〔55〕参见于立深：《〈行政强制法〉实施中若干争议问题的评析》，载《浙江社会科学》2012年第7期。

〔56〕洪家殷：《九十一年度行政法院裁判之检讨——行政秩序罚部分》，载《台湾本土法学杂志》第51期（2003年）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主观故意，而是客观上已不具备充足的财产能力缴纳连续罚款，可是行政机关一如既往地通过课以新的金钱给付义务来促成按日连续处罚确定的先前金钱给付义务，又不采取其他强制执行方式。那么，按日连续处罚的内容最终会因执行力不足而无法实现。二是当事人明明具备缴纳连续罚款的金钱给付能力，却恶意拖延不履行，行政机关仍然重复地强加金钱给付义务，纯属“无用功”。上述两种情况最终会因为执行力不足导致按日连续处罚的内容无法实现。是故，行政机关应将当事人的金钱给付能力纳入执行选择的考量范围，并据此决定是否放弃加处罚款的一贯做法，改选其他强制执行方式。

（二）置于同一行政过程的合法性考察

按照行政过程论的范式要求，理应遵循“正当过程原则”，“以正当性为标准，对整个行政法实施过程进行规范和控制”〔57〕。是故，我们不仅要关注按日连续处罚与加处罚款是否分别满足主体、形式、程序、依据等法定要件，还要重视按日连续处罚实施过程中与加处罚款之间的关联性以及对整体行政过程的合法性、合理性要求。

1. 考察按日连续处罚“合法性”的同时，要兼顾“合理性”

行政合理性原则不仅要求行政行为符合行政目的，而且要平等对待相对人，还要求行政行为的内容符合事物的常规，即行政机关根据法律法规规定的范围、幅度和方式，依具体情况选择适用。具言之，应当尊重客观规律，根据被处罚行业的性质、违法行为的具体原因、被处罚人的认错程度和实际改正能力来判断。

其一，应当考虑“责令立即改正”和“改正期限”是否合理。《按日连续处罚办法》规定的改正时限最长是30日，自送达责令改正违法行为书之日起算。但不是所有违法行为在法定30日内能够完成改正，有些企业在被责令改正后积极进行了整改，由于行业特殊、情况复杂等客观原因使违法行为得到改善，却未完全纠正。譬如“因管理、经营、设备使用等存在问题导致超标排污，环保局责令立即改正具有合理性；如果确因接收污水超出被处罚者的设计水平，导致污水处理系统无法在短时间内恢复，被处罚者尽其所能仍无法在短期内将接收的超标污水处理到符合排放标准，而被处罚者又不能采用停产的方式改正超标排污行为的情况下，则环保局责令立即改正，有违合理性原则。”〔58〕对此，笔者建议，必要时可引入专家质证制度，由专家出具相关意见，作为法院审查“立即改正是否合理”的参考依据。此项举措既可以让被处罚人对裁定结果充分信服，也可以保证司法审判的居中性、公正性。

其二，不应该用客观化的复查标准认定“拒不改正”。“拒”这个字符本身包含很强的主观意味，“拒不改正”不应限于客观存在的违法行为，还应包括主观上的拒绝、不接受。是故，应该审查被处罚人是否存在主观恶意，酌情考虑被处罚人的主观认错程度。倘若被处罚人在收到责令改正的通知后，意识到自己的违法行为造成的不利影响，积极作出整改措施，应当认定其具备改正的主观责任意识，可以将之作为减免处罚的条件，如减少按日连续处罚的罚款数额。

其三，按日连续处罚行为应符合妥当性要求。“不应有过于严苛以致显失公平合理的情形，也不应有过于放纵，以至于根本无法填补违规行为所造成之损害或预防再犯之处罚目的。”〔59〕

2. 按日连续处罚的合法性会影响加处罚款的合法性

〔57〕 江利红：《论行政法实施过程的全面动态考察》，载《当代法学》2013年第3期。

〔58〕 大连清本再生水有限公司诉大连市环保局、市政府行政处罚纠纷案，大连经济技术开发区人民法院（2017）辽0291行初2号行政判决书。

〔59〕 陈清秀：《行政罚法》，法律出版社2016年版，第74页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二者之间有法定的先后顺序性，作出阶段的按日连续处罚在前，执行阶段的加处罚款在后，意味着前行为构成了两行为共享的法律要件，“共同要件引发的实质后果则是关联性的存在和违法性的传染”。〔60〕

首先，按日连续处罚决定的有效存在，是加处罚款的法定要件之一。也可以说，按日连续处罚合法，是加处罚款的不成文合法要件。二者之间是先决关系，要判断加处罚款是否符合法律规定的构成要件，首先要解决的问题是对按日连续处罚合法与否作出判断。在同一宏观行政过程中，按日连续处罚的内容和效力及于后续的加处罚款，行政机关作出加处罚款时，直接以按日连续处罚为基础，将根据按日连续规则计算的罚款数额作为既定事实要件予以采纳。

其次，正常情况下按日连续处罚的违法性应当为加处罚款所继承。鉴于二者之间的纵向执行关系，前行为的瑕疵导致了违法性在前行为与后行为之间的传染。〔61〕问题是，按日连续处罚一旦违法，加处罚款就当然不合法吗？答案不可一概而论，应根据按日连续处罚行为的违法程度据以判断。若按日连续处罚违反法定程序构成重大明显违法，属于无效行政行为，随时可作为应予撤销或无效的事由，主张加处罚款当然违法；若按日连续处罚的违法程度一般抑或轻微，加处罚款的合法性判断应视具体情况而定，譬如行政机关是否在法定期限内撤销了按日连续处罚，程序瑕疵是否对当事人造成实质性影响，“理论上而言，如果先行行为只是轻微违法，后续行为即使继承该瑕疵，也只是轻微违法，原告主张其违法也没有实际意义”；〔62〕若按日连续处罚的合法性尚在待定状态，则不能对加处罚款的合法性轻下结论。正如我国学者所言，先行为违法并不必然导致后行为及最终行为违法，它取决于行为是否独立、瑕疵的重要程度、行为间关系和行为效果的独立性等要素。〔63〕

3. 法院应单独评价加处罚款的合法性

部分学者及法院裁判认为，按日连续处罚被确定违法后，无需对加处罚款再作合法性审查，笔者不以为然。首先，行政过程中的各阶段或各行为虽然相互关联，但彼此之间相互独立，每个阶段或行为的合法性必须单独进行考察和分析，单一阶段或行为的合法性并不代表整体行政法实施过程的合法性。〔64〕按日连续处罚的合法性不能代表加处罚款的合法性，正如有论者所言：“加处罚款的执行决定亦属于合法性审查的范围，被诉或申请执行的具体行政行为中具有加处罚款的内容，它就是该具体行政行为的一个组成部分，因此法院在确认被诉行政处罚决定合法后，还应当对加处罚款决定的合法性进行审查。”〔65〕另有上海市高级人民法院《关于非诉行政执行案件若干问题的解答（二）》第9条规定了“申请执行的具体行政行为涉及加处滞纳金和罚款的，人民法院应当一并审查”。

其次，加处罚款具有单独的可诉性。最高人民法院指出，可诉的行政行为必须具有法效性，即行为直接对外发生法律效果。所谓“直接”，是指法律效果必须直接作用于相对人，导致法律关系的发生、变更或消灭。所谓“对外”，是指行政行为对于行政主体之外的人发生法

〔60〕石肖雪：《宏观行政过程中的关联行政行为认定、效力与救济》，载《苏州大学学报（哲学社会科学版）》2020年第6期。

〔61〕参见石肖雪：《宏观行政过程中的关联行政行为认定、效力与救济》，载《苏州大学学报（哲学社会科学版）》2020年第6期。

〔62〕转引自王贵松：《论行政行为的违法性继承》，载《中国法学》2015年第3期。

〔63〕参见柳砚涛：《行政过程中的先行为效力》，载《东方法学》2017年第4期。

〔64〕参见江利红：《论行政法实施过程的全面动态考察》，载《当代法学》2013年第3期。

〔65〕蔡小雪：《行政处罚的加处罚款在诉讼期间不应计算》，载《人民司法》2008年第11期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

律效果，行政机关之间或行政机关内部的请示报告等内部行为因欠缺对外性而不具有可诉性。如果行政行为的效力仅停留在行政内部领域，并未对公民、法人或者其他组织的权利义务产生直接影响，则不具有可诉性。〔66〕加处罚款不是以新的“罚款”代替原有“罚款”，也不是一个新的“行政处罚”，其本身产生的法律效果是在不免除原有“罚款”义务的基础上增加新的金钱给付义务，迫使当事人履行原基础行政处罚决定的行政执行罚行为，直接对被执行人的权利义务产生实际影响，具备行政诉讼法意义上的可诉性。如有裁定认为：“加处罚款是独立于原行政处罚的另一具体行政行为，其与原行政处罚决定是相互独立的，虽然它们都是使当事人交纳金钱，但是两者的目的、功能和法律后果不同……加处罚款具有单独的可诉性和执行性。”〔67〕

结　语

按日连续处罚与加处罚款作为两种不同的行政行为，归属不同的行政法律框架。前者属于行政处罚，要受到《行政处罚法》的规制，后者属于执行罚，则要接受《行政强制法》的约束。从法律适用上讲，两者不具有可比性。然而，当下理论界对于二者之间的关系尚未达成共识，原因在于按日连续处罚在制度目的和实施方式上具备执行罚的外观，很容易让人误解为按日连续处罚是加处罚款的另一种行政表达。行政实践中执法主体更是将这两个独立的不同类型的单一式行政行为简化为以按日连续处罚为主、加处罚款为辅的复合式行政行为。此举不仅缺乏形式合法性，而且损害了程序正义。为此，本文试图导入行政过程论的研究范式，全面动态考察二者的关联性和承接性。具言之，微观行政过程中注重与行为类型相匹配的适法，尤其是结合新《行政处罚法》，从形式标准、实质标准、构成要件重新界定了按日连续处罚的行为属性，从本质上明确了按日连续处罚和加处罚款的不同之处，并在此基础上建议遵循分别执行的处理原则，分别制作法律文书以及计算罚款数额时区分计算原处罚行为的行政复议、诉讼期间。宏观行政过程中一是准确把握二者之间的依据关系、选择关系，按日连续处罚具有“基础性”，需优先适用，加处罚款具有“执行性”，是可选择的后续保障；二是以正当性为标准，考察“合法性”的同时要兼顾“合理性”；三是加处罚款不当然继承按日连续处罚的违法性，法院应单独评价加处罚款的合法性。概言之，按日连续处罚和加处罚款的某些内容虽有重合，但不可混为一谈，更不能够等同替换。

（责任校对：张军历）

〔66〕天津市中联建通国际物流有限公司诉天津市滨海新区政府行政批复及天津市政府行政复议案，最高人民法院（2018）最高法行审5391号行政裁定书。

〔67〕田东县市场监督管理局与潘林非诉执行审查案，广西壮族自治区田东县人民法院（2019）桂1022行审341号行政裁定书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net